

MEDIDA CAUTELAR EM LICITAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 27-11-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-021165.989.24-5

Representante: Felco Faleiros Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Santa Lucia

Assunto: Medida Cautelar em face da Concorrência Eletrônica nº 005/2024, objetivando a *“revisão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Santa Lúcia, nos termos do Contrato FEHIDRO nº 502/2023, celebrado entre o Município de Santa Lúcia e o Governo do Estado de São Paulo através do Agente Financeiro Desenvolve SP”*.

Responsável: Luiz Antonio Noli (Prefeito)

Advogado cadastrado no e-TCESP: Higor Rafael Macera Estival (OAB/SP nº 330.032).

=====

EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO. CRITÉRIOS DE DESEMPATE. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA TRANSPARÊNCIA E DO JULGAMENTO OBJETIVO. ARTIGO 5º DA LEI Nº 14.133/21. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E DOS ATOS SUBSEQUENTES.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se de representação de **FELCO FALEIROS PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA** que visa à análise de supostas irregularidades praticadas durante o procedimento licitatório da Concorrência

Eletrônica nº 005/2024, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA**, que tem por objeto a *“revisão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Santa Lúcia, nos termos do Contrato FEHIDRO nº 502/2023, celebrado entre o Município e o Governo do Estado de São Paulo através do Agente Financeiro Desenvolve SP”*.

1.2 Apontou a **Representante** que a *“Comissão de Licitação analisou as propostas financeiras apresentadas na referida licitação e verificou propostas aceitáveis de menor valor em empate numérico de R\$ 131.820,81, entre as empresas FELCO FALEIROS, AMPLA e HIPER”*.

Sustentou que, nos termos dos critérios de desempate previstos no edital¹, apresentou sua documentação, sem que fosse ela sequer avaliada pela Administração, que a desclassificou para aprovar a empresa Hiper, *“apenas por esta ter apresentado o registro no SICAF”*.

Argumentou que, *“segundo o edital, o SICAF será utilizado após a etapa de negociação e será verificado pela Comissão, não está explícito que será utilizado como critério de desempate”*.

Entendeu, assim, que a classificação da empresa HIPER em 1º lugar teria sido arbitrária, porquanto *“a comissão criou um critério subjetivo, que em nada avaliou o desempenho contratual prévio da empresa HIPER”*.

¹ 5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Por outro lado, aduziu ter apresentado “*comprovação de excelente desempenho contratual de execução, a inteiro contento e dentro dos prazos estabelecidos em 64 contratos prévios, mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica*”. Além disso, “*os atestados técnicos foram executados pela empresa Felco Faleiros, por meio de suas sócias, ambas com mestrado e doutorado na área (a sócia Cássia de Ávila Ribeiro Junqueira Faleiros também possui MBA na área de saneamento), o que demonstra maior desempenho contratual nos serviços já executados pela empresa, diferentemente de empresas que se utilizam de profissionais apenas graduados para a execução dos serviços. Os diplomas de graduação, mestrado, doutorado e MBA dos sócios também foram apresentados em pasta anexa na plataforma BLL e estão à disposição da Comissão*”.

Afora isso, apontou “*que teria apresentado todos os critérios, em ordem de prioridade, apresentados na Lei 14.133/21 e Edital, que sequer foram avaliados pela Comissão, para o desempate na concorrência eletrônica nº 005/2024: • desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho • desenvolvimento de programa de integridade • empresa licitante localizada no estado/distrito federal do órgão licitante • empresa brasileira • empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país • empresas que comprovem a prática de mitigação*”.

Argumentou, ainda, que teria “*direito em relação à Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações sobre o tratamento diferenciado e simplificado para EPP, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo e Art. à inovação tecnológica*”.

Outrossim, disse que “*a empresa AMPLA foi corretamente desclassificada por apresentar sanções junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União*”.

1.3 Considerando que as questões suscitadas pela Representante poderiam ser esclarecidas pela Administração para subsidiar a decisão desta Corte, foi o Sr. Prefeito notificado para que, no exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, encaminhasse a este Tribunal razões de defesa que entender pertinentes, após o que se decidiria sobre a concessão ou não da liminar pleiteada.

1.4 Notificada, a **Municipalidade** apontou, inicialmente, que a empresa Felco teria apresentado recurso contra decisão que considerou sua proposta inexecutável, ao qual, após análise de mérito, foi negado provimento.

Em seguida, passou a discorrer acerca da legalidade dos critérios de desempate adotados e da desclassificação da ora Representante, que teriam respaldo, em seu entender, no artigo 60 da Lei nº 14.133/21.

Nesse aspecto, sustentou que, sendo inviável a aplicação do inciso I do sobredito artigo, pois as propostas já estariam no exato limite de exequibilidade previsto no artigo 59, § 4º, da mesma lei, passou à avaliação do desempenho contratual das licitantes.

Inobstante o inciso II do artigo 60 mencione o uso preferencial de registros cadastrais, defendeu que sua finalidade é avaliar a eficiência da licitante na execução de contratos anteriores.

Neste contexto, sustentou que a vantagem no torneio deve se direcionar às empresas *“que demonstrarem maior êxito e eficiência na execução pretérita de contratos, não importando a quantidade de contratos executados por cada licitante”*.

Desta forma, entendeu ter sido correta a desclassificação da empresa Ampla Assessoria e Planejamento Ltda., notadamente por possuir *“penalidades referentes a problemas de execução em contratação pretérita”*.

Ademais, acrescentou que a seleção da empresa vencedora se baseou na análise da documentação apresentada por ambas as licitantes, da qual se extraiu que a empresa Hiper *“possui execuções contratuais mais robustas, demonstrando ainda maior capacitação técnica”*.

Argumentou que *“a quantidade de contratos ou atestados de capacidade técnica apresentados pelos licitantes não é o ponto central de análise”*, pois, *“se assim não fosse, o critério de desempate seria a quantidade de contratos assinados e não o desempenho prévio”*.

Outrossim, destacou que *“a empresa Hiper possui contrato vigente com o município de Santa Lucia, cuja execução está ocorrendo de forma exitosa, o que também deve ser levado em conta quando da avaliação da execução pretérita”*.

Desta feita, alegou que o procedimento adotado *“ocorreu com observância dos ditames legais e nos exatos limites do edital do certame, não havendo qualquer mácula a ser sanada”*.

1.5 Na hipótese, as justificativas prévias apresentadas pela Administração, desprovidas de quaisquer elementos probatórios capazes de amparar a tese de superioridade técnica da licitante vencedora, evidenciava, em uma análise apriorística, desrespeito aos princípios da impessoalidade, da transparência e do julgamento objetivo, insculpidos no artigo 5º da Lei nº 14.133/21.

Desta forma, a medida cautelar foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

1.6 Regularmente notificada, a **Representada** argumentou que todos os atos do processo licitatório foram conduzidos em estrita observância à Lei nº 14.133/2021.

Repisou, em linhas gerais, os procedimentos adotados para o desempate das licitantes, defendendo a classificação da empresa Hiper que, a seu ver, teria execuções contratuais robustas e bem-sucedidas, incluindo um contrato vigente com o próprio município.

Concluindo, solicitou a revogação da medida liminar que suspendeu o procedimento licitatório, enfatizando a urgência da questão, pois o recurso obtido teria prazo para ser utilizado.

1.7 O Ministério Público de Contas pronunciou-se pela procedência da representação.

Destacou que o edital deveria especificar de forma objetiva e transparente os critérios de desempate para evitar arbitrariedade e conferir segurança jurídica aos participantes.

No caso em questão, observou que o edital mencionava a utilização preferencial de registros cadastrais para atestar o cumprimento de obrigações, mas não especificava quais registros deveriam ser apresentados. Além disso, a exigência do cadastro no SICAF teria sido dirigida apenas à empresa classificada em primeiro lugar, gerando confusão sobre sua obrigatoriedade.

Sublinhou que, diante da ausência de previsão expressa no edital sobre a utilização do cadastro no SICAF como critério de desempate e a falta de justificativa técnica que confirmasse a superioridade técnica da empresa HIPER, não seria possível atestar a legalidade dos atos praticados pela Administração.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Santa Lucia pretende a contratação de empresa para *“revisão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Santa Lúcia, nos termos do Contrato FEHIDRO nº 502/2023”*.

2.2 No entanto, os elementos constantes nos autos evidenciam não terem sido observados os princípios da impessoalidade, da transparência e do julgamento objetivo, insculpidos no artigo 5º da Lei nº 14.133/21.

A Representante queixou-se, em síntese, da sua desclassificação, apesar de ter *“apresentado todos os critérios, em ordem de prioridade, apresentados na Lei 14.133/21 e Edital, que sequer foram avaliados pela Comissão, para o desempate na concorrência eletrônica nº 005/2024”*.

No entanto, as justificativas da Municipalidade, ao contrário de afastar a ilegalidade apontada, a confirma, porquanto demonstra que os critérios utilizados se basearam em aspectos, de um lado, subjetivos, como a afirmação de que seriam consideradas empresas *“que demonstrarem maior êxito e eficiência na execução pretérita de contratos, não importando a quantidade de contratos executados por cada licitante”* e, de outro, pessoais, haja vista destacar que a *“empresa Hiper possui contrato vigente com o município de Santa Lucia, cuja execução está ocorrendo de forma exitosa”*.

Ademais, há de se destacar que, enquanto a empresa Felco apresentou 64 avaliações positivas de contratos prévios, a empresa Hiper demonstrou a execução pretérita de apenas 22 ajustes, sem que tenha a Administração demonstrado eventual superioridade técnica da empresa por ela classificada.

Nesse sentido, de todo oportuno destacar o parecer do MPC, que bem delineou a matéria:

*“De início, registra-se que, a fim de evitar arbitrariedade por parte da Administração e conferir segurança jurídica aos participantes do certame, devem ser especificados no edital, de forma **objetiva e transparente**, quais critérios serão utilizados na valoração de desempenho anterior das interessadas para fins de desempate.*

Nesse sentido, inclusive, o Manual de Licitações e Contratos do TCU (disponível em <https://licitacoescontratos.tcu.gov.br/wp-content/uploads/sites/11/2024/09/Licitacoes-e-Contratos-Orientacoes-e-Jurisprudencia-do-TCU-5a-Edicao-29-08-2024.pdf>), ao tratar dos critério de desempate, aponta que a ausência de **parâmetros objetivos** para avaliar o desempenho contratual prévio dos licitantes leva à impossibilidade de aplicar o disposto no art. 60, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021, como critério de desempate, com consequente ineficácia do dispositivo legal; ou à aplicação do dispositivo com base em avaliações subjetivas e discricionárias, com consequentes questionamentos e paralisação do certame.

No caso, os critérios de desempate da disputa foram assim discriminados no edital:

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Segundo consta da Ata da Sessão Pública, juntada no evento 47.25 (fls. 7-16), a empresa FELCO foi desclassificada em razão da não apresentação do “cadastro junto ao SICAF” dentre a documentação de desempate, restando classificada a empresa

*HIPER em razão da apresentação do referido cadastro e de “desempenho contratual prévio superior a licitante FELCO”:
(...)*

*Do contido acima, constata-se que assiste razão à representante quanto à ausência de previsão **expressa** no edital acerca da utilização do cadastro junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) como critério de desempate, isso porque, embora o edital preveja que para o desempate “deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais” (item 5.21.1.2), não há no texto convocatório informação acerca de quais registros cadastrais deveriam ser apresentados.*

Além disso, consoante destacado na inicial, verifica-se que a exigência de apresentação do referido cadastro foi dirigida, tão somente, à empresa classificada em primeiro lugar (item 6.1.1 do edital), cenário que, igualmente, gera confusão quanto à obrigatoriedade ou não de sua apresentação dentre a documentação de desempate:

6.1. Encerrada a etapa de negociação, a Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e neste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF: (grifo e destaque do MPC).

Em acréscimo, observa-se que durante a sessão pública houve manifestação da empresa FELCO comunicando que o mencionado cadastro se encontrava inserido junto à documentação de habilitação, de modo que a devolutiva do Agente de Contratação de que “estamos analisando os documentos referente ao critério de desempate e não os documentos de habilitação”, denota, ainda, possível ocorrência de formalismo exacerbado na condução da disputa.

Demais disso, em que pese a argumentação da Origem acerca da existência de comprovação de “execuções contratuais mais robustas, demonstrando ainda maior capacitação técnica” pela empresa HIPER, não constam dos autos e/ou das alegações trazidas pela Administração qualquer justificativa técnica que balize a conclusão pela superioridade da citada empresa.

*Ainda que se admita que o desempate não pode se fundamentar, exclusivamente, em quantidade de atestados, deve-se ter em vista que a avaliação de desempenho deve estar assentada em **critérios objetivos**, contudo, no caso em exame não há informação sobre quais aspectos foram considerados na mensuração da qualificação/desempenho das licitantes (por exemplo, anos de experiência, formação profissional da equipe técnica, quantidade e tipos de contratos executados, serviços de maior relevância, etc.) e/ou demonstração dos comparativos adotados para a aferição de maior e/ou menor desempenho das empresas, estudo sem o qual*

não é possível apurar como a Comissão de Licitação concluiu pela superioridade de uma licitante em detrimento de outra.

No mais, não há como ignorar a aparente discrepância entre a documentação apresentada pela empresa representante – FELCO, que teria comprovado “64 avaliações positivas de contratos prévios” (vide documentação juntada nos eventos 47.8, fl. 21 a 47.17, fl. 2), frente às “22 avaliações positivas de contratos prévios” apresentadas pela empresa HIPER (vide documentação inserida nos eventos 47.17, fl. 5 a 47.23, fl. 18).

Assim, ausente previsão editalícia que especificasse, de forma expressa, a utilização de cadastro junto ao SICAF como critério de desempate, e sem que haja nos autos justificativa técnica que endosse a superioridade técnica da empresa HIPER frente às demais participantes, não há como atestar a legalidade dos atos praticados pela Administração”.

Destarte, bem destacou o MPC que inexistente “*previsão editalícia que especificasse, de forma expressa, a utilização de cadastro junto ao SICAF como critério de desempate*”, assim como não há “*nos autos justificativa técnica que endosse a superioridade técnica da empresa HIPER frente às demais participantes*”.

Patente, assim, que os critérios de desempate adotados pela Administração, afora não terem respeitado o quanto estabelecido pelo próprio edital, deixou de observar os princípios da impessoalidade, da transparência e do julgamento objetivo, insculpidos no artigo 5º da Lei nº 14.133/21.

2.3 Posto isto, considero **procedente** a Representação, determinando, com fundamento nos artigos 71, inciso III, e 171, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, que a Administração promova a **anulação** dos atos que classificaram a empresa Hiper, reavaliando a documentação apresentada, nos estritos termos estabelecidos no edital e nas normas de regência.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO